

1533817-17.2018.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... dos fatos, conhecido como "ponto de tráfico de drogas", abordaram o acusado e encontraram em sua posse uma pequena pedra de crack, droga elaborada a partir da cocaína (pesando 0,1 grama), conforme laudo pericial de pp. 11/14.

Diz, por fim, que o acusado assumiu a propriedade do entorpecente e sua condição de usuário, afirmando que comprou a droga de um desconhecido (pp. 35/36 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1533817-17.2018.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1533817-17.2018.8.26.0562 - Controle n.º 753/19

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DE FREITAS FLORENTINO

Vistos.

ANDERSON FREITAS FLORENTINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, porque no dia 31 de outubro de 2018, pela manhã, na Rua Santa Joana D'arc, nº 2, Morro São Bento, neste município e comarca, trazia consigo, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de pp. 08/09 e auto de constatação preliminar de pp. 6/7).

Diz a denúncia e seu aditamento que policiais civis, em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como "ponto de tráfico de drogas", abordaram o acusado e encontraram em sua posse uma pequena pedra de crack, droga elaborada a partir da cocaína (pesando 0,1 grama), conforme laudo pericial de pp. 11/14.

Diz, por fim, que o acusado assumiu a propriedade do entorpecente e sua condição de usuário, afirmando que comprou a droga de um desconhecido (pp. 35/36 e 65/66).

O acusado não foi localizado pelo Juizado Especial Criminal, razão pela qual o processo foi redistribuído ao juízo comum (p. 69).

Recebida a denúncia (pp. 75/76), foi o réu citado por edital (p. 86). Declarou-se suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do previsto no artigo 366 do Código de Processo Penal (pp. 88/89).

À vista da citação pessoal (p. 144), retomou-se o curso desta ação penal (p. 145). A Defesa ofereceu a resposta de pp. 153/157, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 162/163). Na instrução criminal foi ouvida uma testemunha, procedendo-se ao interrogatório (pp. 206/207).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal, afirmando que o fato não constitui infração penal, diante da ínfima quantidade de droga encontrada em poder do réu e da sua mudança de proceder, que não faz mais uso de entorpecentes (gravação audiovisual pp. 206/207).

A Defesa, em suas derradeiras alegações orais, reiterou os argumentos expostos pelo Ministério Público, pleiteando a absolvição por entender que o dano não transcende a pessoa do usuário, não podendo ser considerado crime, bem como por não haver provas suficientes para a condenação (gravação audiovisual pp. 206/207).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime está demonstrada no auto de exibição e apreensão de p. 8, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de p. 6 e exame químico toxicológico de pp. 11/13, que confirmam a natureza do material estupefaciente como sendo cocaína.

Entretanto, a autoria não foi adequadamente demonstrada.

Perante a autoridade policial, o acusado afirmou que era viciado em drogas e confirmou que havia comprado de um desconhecido a droga encontrada em seu poder (p. 3).

Em juízo, informou que já foi preso anteriormente. Não sabe quem são os policiais arrolados como testemunhas. Acerca dos fatos, nada declarou, exercendo o direito de permanecer calado. Afirmou que atualmente não está trabalhando. Recebe benefício previdenciário por ter sofrido um acidente. Reside sozinho em casa alugada. É solteiro e tem um filho maior. Disse que não faz mais uso de drogas há algum tempo (gravação audiovisual pp. 206/207).

Victor Silverio de Souza, policial civil, relatou que não se recorda desta diligência, visto que já se passaram quase quatro anos e, desde o ano de 2015, realizam operações semelhantes nesta cidade (gravação audiovisual pp. 206/207).

Vê-se, assim, que a prova colhida não é segura para indicar o desate condenatório, sendo forçoso reconhecer que o contexto probatório não é suficiente para a condenação.

Sob o crivo do contraditório, o policial civil aqui ouvido declarou que não se recordava do réu tampouco das circunstâncias que envolveram a detenção dele. Explicou que realizam operações desde o ano de 2015 e, por já ter se passado quase quatro anos desde a ocorrência destes fatos, nada soube relatar a respeito da acusação inicial.

O acusado, por sua vez, no contraditório judicial, preferiu ficar em silêncio.

Todavia, ao contrário do requerido pela Acusação e pela Defesa, não há como reconhecer que o fato aqui apurado não constitua infração penal, pois a posse ilegal de droga destinada a consumo pessoal é conduta típica, sendo irrelevante a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

De outro lado, também não há como entender caracterizada inconstitucionalidade na norma penal prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Apura-se conduta delituosa que afronta e põe em risco a saúde pública, evidenciando-se patente o risco social, bem como se revela potencial e abstrato o dano decorrente do consumo de entorpecentes, pouco importando a lesividade configurada pela quantidade de droga apreendida em cada caso concreto.

Trata-se, por certo, de norma penal que tutela a saúde pública, sendo irrelevante discutir se a repressão ao consumo de entorpecentes, sem autorização legal, representa invasão à privacidade do cidadão.

Não fosse isso, não há dúvida que deve o Estado criminalizar o consumo ilegal de drogas, já que a saúde pública é posta em risco em razão da conduta individualmente considerada. Essa situação é penalmente relevante e, assim, há de ser reprimida.

Vale destacar, ademais, que a pequena quantidade de entorpecentes é característica inerente ao delito em apreço, pois, do contrário, estaríamos diante de forte

indício de mercancia.

Neste sentido, extrai-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"PENAL. APELAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta, alegando a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Descabimento. Absolvição. Impossibilidade.

Constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas é típica, não se vislumbrando a alegada violação a quaisquer princípios constitucionais, tais como o da lesividade e da intimidade. Não apenas o uso propriamente que caracteriza mais seriamente o delito, mas a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para aquela finalidade. O bem jurídico protegido é a saúde pública, em razão do risco que lhe é inerente. A lei não trouxe a descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal, mas apenas a despenalização, a fim de conferir ao usuário de drogas tratamento diverso daquele endereçado ao traficante. Inconstitucionalidade não verificada. O Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, do C. Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a constitucionalidade da criminalização do porte de drogas, está suspenso.

Observância do art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10. Condenação acertada, ora mantida. Negado provimento." (TJSP; Apelação Criminal 1500037-11.2019.8.26.0608; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 23/06/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PORTE DE ENTORPECENTES PARA FINS DE USO - Denúncia rejeitada sob o fundamento de atipicidade da conduta, ante sua insignificância - Porte de substância proscriita que ofende a saúde pública - Conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas que não foi descriminalizada - Tipo que subsiste em consonância com as normas e princípios constitucionais, ainda que não positivados - Pequena quantidade de drogas que é característica do tipo penal em testilha - Recurso provido, com determinação. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1506097-52.2018.8.26.0602; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/10/2020).

Nesse mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"... É inviável a declaração da atipicidade da conduta do paciente pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Embora a constitucionalidade do referido artigo esteja afetada na Suprema Corte, diante do reconhecimento da repercussão geral (Tema 505), nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/RG, ainda prevalece neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não houve a descriminalização do porte de drogas para uso próprio com a entrada em vigor da Lei n. 11.343/2006, mas mera despenalização, tendo em vista a previsão de penas alternativas para o infrator..." (HC 535.785/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019).

Outrossim, extrai-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"... A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III - No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V - A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI - Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a atipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII - Habeas corpus prejudicado." (HC 102940, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011).

Por outro lado, é caso de absolvição, por fundamento diverso, uma vez que circunstâncias relevantes para a convicção judicial a respeito da autoria do crime

que ao réu se imputou não foram adequadamente esclarecidas, sendo forçoso ressaltar, mais uma vez, que não há prova segura que indique a prática do crime de posse de droga para consumo pessoal que ao réu foi imputado. Com efeito, não obstante a prova contida na fase extrajudicial ser importante meio de convicção do juiz, essa deve manter relação com os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, ocasião em que é assegurado e oportunizado o direito ao contraditório.

Nada mais se produziu, sendo forçoso reconhecer que a fragilidade do contexto probatório não permite o desfecho condenatório.

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência". (in, Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, 1983, p. 46).

No mesmo sentido, Hélio Tornaghi leciona: "Nesse caso é que a máxima in dubio pro reo se aplica em toda sua força. Existem, no processo, elementos que levariam a considerar o réu culpado, mas há outros que permitem supô-lo inocente. Estabelece-se a dúvida no espírito do juiz e, nesse estado de incerteza, ele absolve".

(Instituições de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1978. 2.^a ed. vol. 4. p. 393). Assim, e à vista da fragilidade do contexto probatório, necessário que se declare o in dubio pro reo.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para absolver ANDERSON FREITAS FLORENTINO, qualificado nos autos, da acusação que lhe é feita como incurso nas sanções previstas no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, e o faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Santos, 24 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA